

1000810-66.2020.8.26.0095

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... colega chutar Hadonay; que Hadonay é envolvido com tráfico de drogas; que ele já havia sido preso por tráfico; que sempre que faz escolta de preso no hospital coloca uma algema em um braço na cama; que há risco de fuga; que um dos lugares mais fáceis para o preso fugir é no hospital; que ele se queixou de dor em razão de cirurgia que tinha feito depois de os ânimos terem se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas - SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000810-66.2020.8.26.0095 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000810-66.2020.8.26.0095

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Hadonay Vitor dos Santos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Hadonay Vítor dos Santos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que foi preso sob a acusação de que, em 13/01/2020, foi surpreendido na posse de drogas e que foi agredido pelos policiais militares que o abordaram, sendo encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Torrinha e depois para a Santa Casa de Jaú.

Acrescenta que foi algemado em desrespeito à Súmula Vinculante n. 11 do STF. Pede, assim, indenização por danos morais no valor de R\$80.000,00.

Em contestação, a requerida argumentou que o autor tentou fugir no momento da abordagem e reclamou de dores em razão de cirurgia à qual foi submetido anteriormente. Afirmou que o uso de algemas no hospital era necessário devido ao risco de fuga. Subsidiariamente, alega que o valor de eventual indenização deve ser moderado.

Houve réplica (fls. 163/164).

Houve audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidos informantes e testemunhas.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito já se encontra saneado, bem colhidas as provas necessárias ao deslinde do feito.

Isto posto, passo a análise do mérito.

O conceito de responsabilidade civil é objeto de constante divergência doutrinária. Como observa Caio Mário da Silva Pereira, a doutrina tende a vincular o conceito técnico de responsabilidade civil à "obrigação de reparar o prejuízo sofrido por uma pessoa". É dizer: apresenta-se a responsabilidade civil quando alguém está sujeito à reparação de dano experimentado por outrem. Trata-se, portanto, em suma, do dever de ressarcimento.

Consiste a responsabilidade civil, nas palavras de Cavalieri Filho, em "dever jurídico sucessivo", cuja configuração depende de violação a "dever jurídico originário" que tenha provocado um dano. Neste sentido, expõe Aguiar Dias a definição de Marton, qual seja: "a responsabilidade é necessariamente uma reação provocada pela infração a um dever preexistente. A obrigação preexistente é a verdadeira fonte da responsabilidade, e deriva, por sua vez, de qualquer fator social capaz de criar normas de conduta."

Ainda, confira-se a nota de René Savatier sobre o instituto: "a função da responsabilidade é a de restabelecer, tanto quanto possível, o equilíbrio destruído pelo dano, recolocando a vítima, à custa do responsável, na situação em que ela estaria sem o ato imputado a este."

O Código Civil em seu artigo 186, define, genericamente, como ato ilícito a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência das quais decorram a outrem violação de direito e dano, ainda que de ordem exclusivamente moral. O mesmo diploma legal, em seu artigo 927, caput, consignou o dever de reparação do dano.

Destarte, são requisitos elementares para configuração da responsabilidade civil a ação ou omissão, o dano, e o nexo causal, liame que une os dois primeiros pressupostos em relação de causa e consequência. A culpa do agente é elemento accidental, analisado ao se tratar de responsabilidade subjetiva.

Quanto à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva e baseia-se no risco administrativo, incumbindo à vítima demonstrar apenas que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal ilícita, sendo desnecessário tecer considerações sobre dolo ou culpa.

Desta forma, suficiente a demonstração de três requisitos: i) conduta administrativa ilícita atribuída ao Poder Público; ii) ocorrência de dano; iii) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Anoto, ainda, que, no caso concreto, o ato ilícito concernente ao uso alegadamente indevido de algemas ventilado pelo autor consiste em ato administrativo praticado no contexto do poder de polícia da Administração Pública, que tem, por regra, caráter discricionário, a respeito do qual leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro: "Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, além do fato de corresponder a uma atividade negativa. Pode-se atualmente acrescentar outra característica, que é a indelegabilidade do poder polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Quanto à discricionariedade, embora esteja presente na maior parte das medidas de polícia, nem sempre isso ocorre. Às vezes, a lei deixa certa margem de liberdade de apreciação quanto a determinados elementos, como o motivo ou o objeto, mesmo porque ao legislador não é dado prever todas as hipóteses possíveis a exigir a atuação de polícia. Assim, em grande parte dos casos concretos, a Administração terá que decidir qual o melhor momento de agir, qual o meio de ação mais adequado, qual a sanção cabível diante das previstas na norma legal. Em tais circunstâncias, o poder de polícia será discricionário. Em outras hipóteses, a lei já estabelece que, diante de determinados requisitos, a Administração terá que adotar solução previamente estabelecida, sem qualquer possibilidade de opção. Nesse caso, o poder será vinculado." (in Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 32. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Também é característica de qualquer ato administrativo a presunção de legitimidade

e veracidade, presunção que tem o condão de inverter o ônus da prova em desfavor do particular, conforme ensina a mesma autora:

"Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção de legalidade, abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de outro lado, a presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. Trata-se de presunção relativa (*juris tantum*) que, como tal, admite prova em contrário. O efeito de tal presunção é o de inverter o ônus da prova. Como consequência dessa presunção, as decisões administrativas são de execução imediata e têm a possibilidade de criar obrigações para o particular, independentemente de sua concordância e, em determinadas hipóteses, podem ser executadas pela própria Administração, mediante meios diretos ou indiretos de coação." (in *Direito administrativo* / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 32. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Como decorrência dessas características do ato administrativo, deve-se registrar que, em razão da autonomia e independência dos Poderes, ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo interferir nos critérios que ensejaram a sua prática, de modo que só lhe é permitido avaliar os elementos de validade e o respeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nessa linha, ensina Hely Lopes Meirelles:

"a competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle de legalidade e da legitimidade do ato impugnado. (...) O que não se permite ao Poder Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito" (*Direito Administrativo Brasileiro*, 35ª edição, pág. 717/718, g.n.).

Feitas essas considerações teóricas, no caso concreto, o autor alega que foi agredido pelos policiais quando não era necessário uso de força física e que foi algemado indevidamente quando internado no hospital.

Trouxe a parte autora aos autos, como elementos probatórios, documentos (fls. 10/16) e prova testemunhal. A ré também trouxe documentos e arrolou testemunhas que foram ouvidas como informantes na audiência de instrução e julgamento realizada. Em suma, os documentos revelam que o autor foi preso em flagrante, junto de Rafael Checco dos Santos, por estarem na posse de entorpecentes na data de 13 de janeiro de 2020. Os policiais, em Delegacia, afirmaram que o autor inicialmente tentou fugir da abordagem, mas que naquele momento, após ser detido, não foi necessário o uso de algemas. Ainda, registraram que Hadonay reclamava de dor em razão de cirurgia de hérnia inguinal que havia feito há um tempo, sendo, então, encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado.

A prisão em flagrante de Hadonay e Rafael Checco foi convertida em prisão preventiva (fls. 118/119). Posteriormente, quando realizada a audiência de custódia de Hadonay, foi mantida a prisão preventiva (fls. 144), bem como foi registrado o relato do autor acerca das alegadas agressões policiais, com determinação de realização de exame de corpo de delito e envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar.

O exame de corpo de delito do autor não apontou lesões (fls. 148).

A testemunha Rafael Checco dos Santos, ouvida em juízo, disse que foi feita a abordagem pela polícia militar, que encontrou droga no carro; que a polícia agrediu Hadonay com dois chutes no estômago; que estava junto com Hadonay; que saíram do carro e deitaram no chão e a polícia deu dois chutes; que estava do lado dele; que achou que ia apanhar também; que não tinha nem como ele resistir ou fugir; que foi o Boldan (apelido do policial) quem chutou; que ele reclamou de dor; que depois do

hospital não viu mais Hadonay; que não tinham problemas com os policiais; que antes de ser abordado ele estava tranquilo; que foi por causa do chute que ele passou mal; que depois ele começou a suar frio; que não sabe se Hadonay fez alguma cirurgia antes.

O informante Rodrigo Rodrigues Silva, policial militar, disse que realizaram a abordagem e Hadonay estava do lado do motorista; que conteve Rafael e Hadonay correu; que seu parceiro foi atrás de Hadonay; que contiveram os dois ali no lugar; que Hadonay reclamou de dores porque tinha feito cirurgia de hérnia há alguns dias; que quanto à escolta foi o efetivo de Jaú quem fez; que uma viatura de Brotas o encaminhou, escoltando a ambulância; que Hadonay já fugiu uma outra vez algemado também; que não viu o colega chutar Hadonay; que Hadonay é envolvido com tráfico de drogas; que ele já havia sido preso por tráfico; que sempre que faz escolta de preso no hospital coloca uma algema em um braço na cama; que há risco de fuga; que um dos lugares mais fáceis para o preso fugir é no hospital; que ele se queixou de dor em razão de cirurgia que tinha feito depois de os ânimos terem se acalmado; que foi instaurado um procedimento administrativo; que coronel pediu o arquivamento; que não sabe se a vítima e a testemunha foram ouvidas.

O informante Edmar Carneiro Boldan, policial militar, disse que fez a condução de Hadonay; que correu atrás do Hadonay; que teve que usar força física para dominá-lo para que ele não se evadisse; que fez a busca veicular, enquanto o outro policial militar estava com os autuados; que Hadonay reclamou de dor abdominal; que houve força física de ambos os lados; que ele falou que tinha feito cirurgia abdominal; que não fez escolta até o hospital; que não é incomum o preso ficar algemado no hospital, porque é alto o risco de fuga; que estava de frente do lado do Hadonay; que o outro policial ficou do lado do Rafael; que no local quando já estavam sob a guarda do sargento, não foi necessário o uso de algemas; que para condução ao hospital não foram utilizadas algemas.

Ainda na audiência de instrução e julgamento, o autor pediu produção de prova pericial, que foi indeferida com fundamento na preclusão.

Anoto, ademais, que os documentos apresentados juntamente com a réplica não podem ser considerados, pois o artigo 434 do CPC é claro ao dispor que o momento processual para produção de prova documental é com a apresentação da petição inicial ou da contestação. Veja-se:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes."

O artigo 435 do CPC excepciona a regra ao permitir a juntada de documentos novos, nos seguintes termos:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

No caso, a petição inicial foi distribuída em 12/06/2020 e os documentos de fls. 165 e seguintes são de datas anteriores, de modo que não podem ser considerados documentos novos, mesmo porque o autor não se desincumbiu do ônus legal, do qual já tinha ciência, por decorrer da lei, de comprovar motivo que o impediu de juntá-los anteriormente.

Nesse contexto fático probatório, em relação à alegada agressão da qual o autor teria sido vítima, reputo que não há provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, pelas provas que podem ser consideradas nos autos, não há clareza a respeito da integridade física do autor após os fatos.

A ficha de atendimento médico de fls. 14 é quase integralmente ilegível, e,

portanto, não há como saber se, no caso, o autor foi encaminhado ao hospital por dores decorrentes de prévia cirurgia ou por agressão dos policiais. Mesmo que fossem considerados os exames médicos juntados intempestivamente pelo autor, a prova pericial também está coberta pela preclusão, prova que seria indispensável para avaliar a possível associação dos laudos médicos com a alegada conduta do policial.

A prova testemunhal, nesse contexto, embora tenha versado a respeito da alegada agressão sofrida pelo autor, restou isolada em cotejo com o restante do conjunto probatório. Por oportuno, ressalto que a prova testemunhal tem caráter subsidiário, nos termos do artigo 443 do Código de Processo Civil.

Em relação ao emprego de algemas, a conclusão é diversa.

No caso concreto, estão comprovados a conduta, o nexo de causalidade e o dano moral, a ensejar a responsabilidade civil do Estado, cujas características foram abordadas acima.

Isso porque há prova de que o autor permaneceu algemado enquanto estava no hospital e não há qualquer justificativa por escrito a respeito da excepcionalidade do uso de algemas, conforme determina a Súmula Vinculante n. 11: "Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". Não havendo qualquer justificativa concreta por escrito, reputo que o uso de algemas enquanto o autor estava internado consiste em ato ilícito. A propósito, deve-se destacar que a ré não trouxe prova escrita ou testemunhal que pudesse suprir a justificativa escrita a respeito da necessidade do uso das algemas de forma concreta e específica. Os informantes apenas afirmaram, de forma genérica, que é comum o uso de algemas para presos em flagrante internados em hospitais, mas os policiais que prestaram depoimento como informantes não puderam dizer nada a respeito da situação em concreto, pois dela não participaram. A dúvida se eleva acerca da necessidade do uso de algemas diante do fato de que, mesmo durante a prisão em flagrante, o uso não foi necessário, conforme registrado pelo policial. Assim, o ato administrativo, diante das peculiaridades neste caso verificadas, não pode ser considerado presumidamente legítimo, por lhe faltar requisito essencial exigido pela Súmula Vinculante n. 11.

Em relação a dano sofrido, anoto inicialmente que o conceito de dano extrapatrimonial está atrelado aos direitos da personalidade, que ganharam destaque constitucional com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho assinala que o dano moral é a lesão ao direito geral de personalidade, premissa sob a qual a Constituição inseriu em seu art. 5º, inc. V e X, a sua plena reparação: "Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável." (Programa de responsabilidade civil. 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).

O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a dor experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se verifiquem esses efeitos. Todavia, também não se confunde com meros transtornos ou dissabores, pois o standard do direito geral da personalidade não pode se apoiar em situações de sensibilidade exacerbada, sob pena de vulgarização da figura.

No caso em análise, partindo da premissa de que houve ato ilícito por parte dos agentes públicos no emprego indevido de algemas, considero que está configurado o dano moral, pois o ato ilícito atinge a liberdade de locomoção, bem como constrangimento desnecessário em momento no qual o autor já estava em circunstâncias de fragilidade, por estar internado para tratamento de sua saúde.

Sobre quantificação do dano moral, destaco que a mensuração da indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o propósito a que se destina, para que não se permita o enriquecimento ilícito, tampouco que a reparação se torne inócua.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que,

de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 155).

Diante da situação narrada nos autos, reputo adequada a fixação da reparação por dano moral em R\$5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função preventiva exercida pelo instituto da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora. Tal critério já foi adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em caso semelhante:

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE POR ATO COMISSIVO. DANO MORAL. Diligência policial. Violência e arbitrariedade dos agentes públicos. Invasão de domicílio, lesões corporais e uso indevido de algemas. Responsabilidade objetiva. (...). Autorização concedida pelos moradores para que houvesse o ingresso na residência, mesmo sem a existência de mandado judicial, aponta para o excesso na ação policial consistente na manutenção de um dos moradores algemado e ajoelhado durante o período noturno até o fim da diligência. DANO MORAL. Critério empregado para arbitramento da indenização. Razoabilidade e discricionariedade diante da causa de pedir. A indenização revela duplo sentido. A compensação pelo sofrimento e a sanção inibitória. Indispensável evitar o enriquecimento sem causa. Imprescindível considerar o grau de culpa, o dano em si, as condições econômicas e sociais da vítima e do ofensor. O valor fixado é adequado para inibir distorções e evitar quantificações inexpressivas ou exageradas. Razoabilidade determina o arbitramento da verba indenizatória em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECUTÓRIOS LEGAIS. Juros de Mora. Súmula 54 do STJ. Incidência desde a data do ilícito. Correção monetária devida desde o arbitramento da indenização. Súmula 362 do STJ. ADIs 4357 e 4425. Efeito vinculante. Inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Declaração prospectiva de inconstitucionalidade. Termo inicial em 25.3.2015. Aplicabilidade da norma no período compreendido entre a data da sua vigência (30.6.2009) e o referido marco temporal. Aplicação do artigo 406 do Código Civil. Juros moratórios a razão de 1% a.m. desde o ilícito sem qualquer correção monetária até a data de início de vigência da Lei n. 11.960/2009 (30.06.2009). Entre 30.06.2009 e 25.03.2015, aplica-se a Lei n. 11.960/2009 e, a partir de então até a data do efetivo pagamento, deve incidir a Taxa Selic Natureza híbrida. Precedente do STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 0022116-97.2009.8.26.0482; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2015; Data de Registro: 24/06/2015, grifos nossos).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais fixada em R\$5.000,00.

O valor da indenização deverá ser corrigido pelo IPCA-E, desde a data desta sentença (Súmula n. 362 do STJ), e acrescido de juros de mora em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em atenção ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 do STF, cuja decisão transitou em julgado em 03/03/2020), desde o evento danoso (data da internação), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Tais critérios serão aplicáveis até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a recente entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, não cumulável com quaisquer outros índices, porque inclui, a um só tempo, o índice de correção e juros (Súmula 188 e 523 do STJ).

Em face do princípio da sucumbência, a ré deve ser condenada a ressarcir as custas

e despesas processuais despendidas pela parte autora e a pagar os honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, fazendo-o com fundamento no artigo 85, §2º e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em caso de recurso, ouça-se a parte contrária e remetam-se os autos à instância superior. Dispensada a remessa necessária, em razão do valor envolvido (artigo 496, §3º, inciso II, do CPC).

Com o trânsito em julgado, expeçam-se eventuais certidões de honorários e, sem outros requerimentos, arquivem-se.

P.I.C.

Brotas, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA